



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 49/13

בענין : חן גור ת.ז. 037648045

התובע

ע"י ב"כ עו"ד יוני עמנואל
מרח' ירושלים 46 חדרה 38382
טל': 072-2529994, פקס: 072-2529997

נ ג ד

1. אופירה מזרחי ת.ז. 09567736
ע"י ב"כ עו"ד תמיר לוי
מרח' ישעיהו 24 חדרה 38278
טל': 04-6265455, פקס: 04-6265452

2. גרשון לופו ת.ז. 67506469
יהודית לופו ת.ז. 6385223
רח' רוטשילד 62/4, חדרה

3. לזרין שירי ת.ז. 43687052
רח' רוטשילד 62/8, חדרה

4. גרשון צבאח ת.ז. 04333574
מרח' רוטשילד 62/3, חדרה

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. התובע, בעלים של דירה בבית המשותף המזוהה כחלקה 33 בגוש 10034 ברח' רוטשילד 62, חדרה (להלן: "הבית/המשותף") הגיש תביעה כנגד הנתבעים, בעלים של 4 דירות אחרות בבית המשותף, בה עתר לצו עשה אשר יורה להם להרוס ארבעה מחסנים שבנו בשטח המשותף לנתבעים, לתובע ולבעלי דירות נוספים בבית, וכמו כן לפתוח את המעבר הדרומי לבית אשר נחסם באמצעות שער על ידי הנתבעים.

טענות התביעה בתמצית-

2. התובע אשר רכש לאחרונה את דירתו מצא כי על שטח הצמוד לו במשותף עם בעלי דירות אחרים בבית בנויים ארבעה מחסנים אשר נמצאים בשימוש ייחודי של הנתבעים, מחסן אחד לכל נתבע. מבדיקה שערך גילה כי מחסנים אלו נבנו

ללא היתר בניה וללא הסכמתם של יתר בעלי הדירות בבית ועל כן הם מהווים השתלטות על שטח משותף.

3. הנתבעים הקימו שער החוסם את הכניסה הדרומית לבית ומונעים מהתובע מעבר דרכו אל הבית.

4. לצורך בניית מחסן נדרשות הסכמות של כל בעלי הדירות בבית להם צמוד השטח "ג" עליו נבנו. אין לקבל את מסמך ההסכמות אשר צירפו הנתבעים היות ונערך בשנת 2013, שנים רבות לאחר שהמחסנים נבנו. יצוין כי מסמך זה גם אינו כולל את הסכמות כל בעלי הדירות. הנתבעים מודים כי לא קיבלו הסכמות פוזיטיביות של כל בעלי הדירות שבבעלותם אותו שטח "ג" עליו נבנו המחסנים.

5. אין לקבל את הטענה כי העדר התנגדות אקטיבית של יתר בעלי הדירות בבית הקנתה לנתבעים זכויות קניינות במחסנים.

6. העובדה שהנתבעים לא טרחו להביא לעדות את בעלי הדירות האחרים בבית (נותני ההסכמה) פועלת לחובתם.

7. אפילו היה מוכח כי ניתנה הסמכה לבניית המחסנים, הסכמה זו לא יכולה לחייב את התובע כל עוד לא נרשמה בספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית או בלשכת רישום המקרקעין. אפילו הייתה מוכחת רשות, הרי שרשות זו באה אל קיצה עם גילוי דעתו של בעל דירה המתנגד לה-התובע, מקום בו לא הוכח כי ניתנה תמורה כלשהי ע"י הנתבעים.

8. אין לקבל את הטענה להתיישנות שכן עילת הסגת גבול היא "עוולה מתמשכת" המתחדשת מדי יום.

טענות ההגנה בתמצית-

9. הנתבעים, כמו גם רבים מבעלי הדירות בבית, הם מבוגרים ובעלים ותיקים של דירות בבית. התובע אשר רכש דירתו רק בשנת 2012 או בסמוך לכך החל להשתלט על חלק נכבד של החצר באמצעות בניית גדר בלתי חוקית מבלי שקיימות בידי הסכמות מאת יתר בעלי הדירות בבית, והוא מנסה לשנות סדרי עולם במקום.

10. הנתבעים יחד עם בעלי דירות רבים אחרים בבית הגישו תביעה לסילוק ידו של התובע מאותו שטח. כתוצאה מכך, ועל מנת להלך אימים על הנתבעים, הוגשה תביעה זו. התנהגות התובע עולה כדי חוסר תום לב ושימוש לרעה בהליכי משפט.

11. בינן לבין, ביום 1.10.13, נתן כב' בית משפט השלום בחדרה פסק דין המורה לתובע לסלק ידו מהחצר המהווה רכוש משותף.
12. התובע מנהל בדירתו עסק לממכר משקאות אלכוהוליים, תוך שהוא חוסם את המדרכה, משתלט על שטחים משותפים ויוצר מפגעים ומטרדים בבית.
13. התובע בעצמו טוען כי המחסנים נבנו כבר בשנת 1999 ועל כן תביעתו של התובע התיישנה או לכל הפחות נגועה בשיהוי.
14. הנתבעים עושים שימוש במחסנים שנים רבות ומכוח הסכמות של כל בעלי הדירות אשר היו בעלים נכון למועד שנבנו. המחסנים קיימים משנת 1999 וללא שנשמעה עד למועד הגשת התביעה כל טענה או דרישה בקשר אליהם.

ההליכים בתיק-

15. ביום 26.12.13 התקיים דיון הוכחות בו העידו מטעם התביעה התובע, ומטעם ההגנה נתבעת מס' 1 ונתבע מס' 2. עם סיום דיון ההוכחות ניסיתי להביא את הצדדים להסכמות לכך שיותר לתובע לבנות לעצמו מחסן בהמשך לשורת המחסנים נושא ההליך אשר בנו הנתבעים. הצדדים דחו את הצעתי זו, ועל כן הוריתי לצדדים להגיש סיכומי טענות בכתב. התובע הגיש סיכומים מטעמו בהם חזר על עיקרי טענותיו לעיל, ואילו הנתבעים, על אף שניתנה להם אורכה להגשת סיכומי טענות עד ליום 1.3.14, לא הגישו סיכומי טענותיהם עד לרגע כתיבת שורות אלו.
16. על אף העובדה שהנתבעים לא הגישו סיכומי טענותיהם לא מצאתי מקום ליתן פסק דין כנגד הנתבעים על סמך כתב הטענות בלבד.
17. הטעם לכך הוא שאי התייצבותו של בעל דין לדיון שנקבע, ובאופן דומה-אי הגשת סיכומים על ידי בעל דין- אין בה כדי להקנות לצד שכנגד זכות לקבלת פסק דין על פי כתב טענותיו. בדונו בתקנות 160(ד) ו-157(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 הגדיר המלומד זוסמן בספרו "סדר הדין האזרחי" (מהדורה שביעית, 1995), בעריכת ד"ר שלמה לויין בעמ' 513 ה"ש 217, את הכלל הבא:
- "כך, למשל, אם לא הגיש הנתבע סיכומי טענות בכתב, אין התובע זכאי למתן פסק דין, אלא, על בית המשפט לבחון, על יסוד הראיות, מהו פסק הדין שמן הראוי לתתו".
- וכן ראו ע"א 28/66 "דן" אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ נ' "בחן" חברה לביטוח בע"מ, פ"ד כ' 602; רע"א 5451/96 זימן נ' מזרחי (פורסם במאגרים המשפטיים, 28.12.1998; הפב(מרכז) 13403-09-08 ויואנס בע"מ נ' "

האגף להספקת משאבים של משרד הפנים של אוקראינה (פורסם במאגרים המשפטיים, 26.2.12).

18. לאור זאת אני סבורה כי מן הראוי שפסק הדין יינתן על סמך הראיות הקיימות בתיק.

דיון והכרעה-

טענות בדבר התיישנות ושיהוי בהגשת התביעה-

19. דינה של טענת ההתיישנות להידחות. ההלכה הפסוקה קובעת כי הסגת גבול במקרקעין היא עוולה מתמשכת, במובן זה שעילת התביעה מתחדשת מיום ליום, ולפיכך אינה מתיישנת. ראו ע"א 35/71 חב' ישראל אוסטרליה בע"מ נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כז' (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם.

20. לא מצאתי כי התובע השתהה בתביעתו. הנתבעים עצמם מודים בכתב הגנתם כי התובע רכש את הנכס בשנת 2012 ומחומר הראיות עלה כי כבר באותה השנה הוציא מכתבי דרישה המופנים לנתבעים בהם דרש את פינויים של המחסנים.

טענות שמקורן בדיני התכנון והבניה-

21. את הטענה כי הנתבעים נעדרים היתר בנייה כדין צריך/רשאי התובע להפנות לוועדה המקומית על תכנון ובנייה האמונה על הפן התכנוני. המפקח על רישום מקרקעין אמון על בחינת זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות בבית, זאת להבדיל, כאמור, מזכויותיהם התכנוניות. וראו בעניין זה את הדברים שנאמרו בע"א 402/80 אתגר נ' מ.ב.א פד"י לה(3) 309. משכך, המפקח על רישום מקרקעין אינו הגוף אשר אמון על אכיפת הצורך בקבלת היתר בניה כדין.

הרוב הדרוש לשם קבלת חזקה ייחודית-

22. סעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע:

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (הדגשה שלי י.ל.).

23. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי המחסנים נושא ההליך נבנו על שטח הקרקע המסומן בתשריט רישום הבית המשותף באות "ג". מעיון בנסח הרישום עולה כי שטח קרקע זה הוצמד ל-15 יחידות (מתוך 26 יחידות הקיימות בבית), הן תתי חלקה: 3-7, 9, 10, 12-19, הכוללות גם את היחידות שבבעלות התובע והנתבעים. לאור זאת, ברי כי שטח הקרקע עליו בנויים המחסנים הוצמד הן ליחידות התובע, הן ליחידות הנתבעים.

24. באנלוגיה להוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין, לעיל, שימוש ייחודי של בעל דירה באופן בלעדי בחלק משטח ההצמדה כמוהו כהצמדתו של אותו שטח לאותו בעל דירה. כאשר בעל דירה תופס חזקה ייחודית באותו שטח מונע הוא, הלכה למעשה, באופן מוחלט מבעלי הדירות האחרים להם צמוד אותו השטח לעשות שימוש באותו החלק אשר הוצמד גם להם. כשם שעשיית שימוש ייחודי בשטח המהווה רכוש משותף דורש הסכמת כל בעלי הדירות שבבית המשותף, כך כאשר מדובר בעשיית שימוש ייחודי בשטח הצמוד בצמידות משותפת למספר דירות נדרשת הסכמתם של כל אותם בעלי דירות.

25. על בנייה כגון דא לא ניתן להחיל את הוראת סעיף 71ב לחוק המקרקעין הקובע כי לשם הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה די בהסכמה של 3/4 מבעלי הדירות ש-2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, היות ו-"הרחבה" מוגדרת באותו הסעיף כ-"**הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף**". הנתבעים הודו בעדותם כי לא התקבל היתר בניה למחסנים (ראו עדות נתבעת מס' 1 בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 39-41). היא הנותנת שכבר מטעם זה לא ניתן להחיל על בנייה זו את הרוב המופחת הקבוע בסעיף 71ב לחוק המקרקעין.

26. למעלה מהדרוש אציין כי אפילו היה קיים היתר בניה למחסנים אלו, עדיין לא ניתן היה לראות בהם "הרחבה" כמשמעותה בחוק המקרקעין. זאת משום שהפסיקה קבעה כי במצב דברים בו מבקש בעל דירה לבנות מחסן לדירתו, כאשר המחסן איננו מהווה חלק אינטגרלי מדירתו, שכן איננו צמוד אליה פיסית, כבמקרה דנן, לא ניתן לראות בכך "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71ב לחוק המקרקעין. ראו בעניין זה את אשר נקבע ברע"א 1462/10 עטייה נ' שגיא (פורסם בנבו) שם נקבע כדלהלן:

"לאחר שבחנו את ההסדר הקבוע בסעיף 71ב לחוק המקרקעין ועמדנו על התכליות העומדות בבסיסו ועל שיקולים פרשניים נוספים הצריכים לעניין, הגענו לכלל מסקנה כי הצמדה של חלק מסוים ברכוש המשותף שאינו מצוי בסמיכות פיסית לדירה אינה בבחינת "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71ב לחוק".

27. אין חולק כי במקרה דנן מדובר על מחסנים אשר נבנו על גבי שטח הקרקע הצמדה "ג" אשר הינו מנותק מהדירות בבית המשותף באופן שאין מחלוקת כי לא קיים רצף טריטוריאלי בין הדירות לבין המחסנים, והללו אינם יכולים להיחשב חלק אינטגרלי מהדירות. וראו בהקשר זה גם את עדות הנתבעת מס' 1 בעניין בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 6-2.

28. לאור זאת, ברי כי סעיף 71 לחוק המקרקעין אינו חל על בנייתם של מחסנים אלו ומשכך נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות אשר להם צמוד שטח "ג".

האם הנתבעים קיבלו הסכמות פוזיטיביות של בעלי דירות אלו?

29. נתבעת מס' 1 העידה כי בניית המחסנים נעשתה בהסכמת כל בעלי הדירות בבית, כי ההסכמה הוגשה לעיריה אך לא נמצאה. ראו עדותה בעמ' 6 לפרוטוקול שורה 7 וכן עדותה בעמ' 7 שורות 33-31. לא היה בידי מי מהנתבעים מסמך המכיל את חתימותיהם של מי מבעלי הדירות נכון למועד בניית המחסנים. משכך, פנו הנתבעים בשנת 2013 אל בעלי הדירות בבית והחתימו אותם על אישור בדיעבד להקמת המחסנים, מסמך נ/2, המאשר כי כבר בשנת 2000 נתנו הסכמתם לבניית המחסנים. אינני מוצאת צורך לדון בטענת התובע כי אין לקבל הסכמה זו בהיותה הסכמה בדיעבד, מהטעם שממילא אין מחלוקת בין הצדדים כי מסמך זה אינו מכיל את חתימתם של כל בעלי הדירות בבית להם צמוד שטח "ג".

30. נמצא אם כן כי לא הוכח כי ניתנה לנתבעים הסכמת פוזיטיבית של כל בעלי הדירות אשר הוצמד להם שטח "ג" עליו נבנו המחסנים עת נבנו.

האם הוכחה הסכמה בעל פה או הסכמה שבשתיקה ומשמעותה-

31. כבר נקבע בפסיקה כי ויתור על זכויות קנייניות דורש הסכמה מפורשת וברורה ואין די בהסכמה בשתיקה או בהסכמה משתמעת. ראו ע"א 7388/97 **עזבון משה שמיר ז"ל נ' דולב (שמיר)** פ"ד נה' 690, בר"ע 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78 נקבע כי גם הסכמה מפורשת בע"פ הסכמה היא.

32. להבדיל מויתור על זכויות קנייניות כאשר מדובר בזכות שימוש ייחודית במקרקעין, ניתן ללמוד על הסכמה גם בדרך של שתיקה, הסכמה מכללא או על דרך של בחינת התנהגות הצדדים במשך השנים. ראו ע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא (3) 210, שם נקבע כי העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע, ובמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא:

"הלכה פסוקה היא... שלשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה התנהגותם של בעלי הדין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימוש של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס האדם את הקרקע, ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא (implied license) שלא היה קיים מלכתחילה..."

וראו גם ע"א (מחוזי י-ם) לומברוזו נ' קובנר (ניתן ביום 7.8.07).

33. יפים לעניין זה גם דבריה הבאים של פרופ' נינה זלצמן במאמרה **רישיון במקרקעין**, הפרקליט מב' חוברת א' בעמ' 128 :

"לצד רשות שניתנה בהבטחה מפורשת ניתן לתאר מצבים בהם נלמדת הסכמתו של בעל מקרקעין, ומכאן רשותו, משתיקתו ואי מחאתו על ההחזקה של פלוני בנכס, או על השימוש שהוא עושה בנכס, כאשר בנסיבותיו של המקרה ניתן היה לצפות את התנגדותו. במצבים אלה ההחזקה או השימוש הושגו במעשה עוולה של הסגת גבול במקרקעין. אך השלמתו של בעל מקרקעין עם נוכחותו של פלוני בנכס מניחה עם עבור הזמן את הסכמתו שבשתיקה...הסכמה זו משמעותה היתר של רצון טוב המתחדש מרגע לרגע כל עוד לא גילה בעל המקרקעין את דעתו שהוא חפץ בסיומו..."

34. עוד נקבע בפסיקה כי הזכות הנוצרת עקב הרשות, היא זכות אישית (in personam) נגד נותן הרשות בלבד להבדיל מאותן זכויות (in rem) השרירות נגד כלל בני-אדם. וכך נקבע בע"א (ת"א) 271/85 הילמן נ' רוזן, פ"מ תשמ"ז(1) 283 :

"רשות חינם ניתנת לביטול בכל עת על-ידי כך שנותן הרשות מגלה דעתו כי אין ברצונו להרשות יותר את הפעולות לגביהן ניתנה הרשות, וכן באה הרשות לקיצה ע"י כל העברה של המקרקעין נשוא הרשות..."

35. רק במקרים מיוחדים, בהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושהבן קיימת הסתמכות של בעל הרישיון על ההסכמה, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם. ראו לדוג' ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט (2) 419 וכן ראו ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, פ"ד מו (5) 184.

36. נקבע עוד כי הסכמה בעל פה תחייב גם צדדים שלישיים דהיינו חליפיהם של בעלי הדירה שנתנו הסכמתם רק אם ידעו על קיומה. ראו בעניין זה את פרשת הילמן, לעיל שם נקבע :

"סעיף 71 לחוק המקרקעין מבטיח, בין היתר, שהסכם שהושג בין בעלי הדירות בזמן מסויים, יחייב - לזכות ולחובה - גם את בעלי הדירות שיבואו במקומם,

ובלבד שאותו הסכם נרשם ב"ספר החלטות". על סעיף 71 הנ"ל אמר כב' הנשיא לשעבר לנדוי בע"א 815/81 [3] הנ"ל (בעמ' 83):

"הסעיף אינו אומר, שהסכמה שלא ניתנה בכתב חסרה תוקף. הדגש שבו הוא הרחבת ההסכמה, שהסכימו בעלי הדירות בהווה, והחלטה גם על כל מי שירכוש בעתיד דירה מן הדירות שבבית. הרחבה כזאת תיתכן, רק אם ההסכמה ניתנה בצורת החלטה, שנרשמה בספר הפרטיכלים של האסיפה הכללית..."

37. שמירת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות בבית משותף משמעותה כי יש להקפיד הקפדה יתרה פן תתפרש שתיקתם כהסכמה ממנה לא ניתן לחזור. וראו הדברים שנאמרו בת"א (מחוזי ת"א) 2813/03 קונצ'יצקי נ' שפרן (ניתן ביום 3.4.06), שם נאמר:

"בהסקת מסקנות בדיעבד בדבר אישור השימוש הייחודי בגג הבית המשותף יש משום הגמשה של כללי ניהול הבית המשותף, תוך שלילת הוודאות ומתן אפשרות ליצירת זכויות על ידי קביעת עובדות בשטח. אישור שכזה מנוגד לתכלית הראויה...ואולם, גם בהנחה המיטיבה עם המשיבים שתיקת המערערים במשך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שאותו עשו בגג הבית, הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאה חינם שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון.."

מן הכלל אל הפרט-

38. עדות נתבעת מס' 1 בעניין ההסכמות הנדרשות לא הייתה סדורה ועקבית. בעדותה בעמ' 6 לפרוטוקול שורה 7 העידה העדה כי בניית המחסנים נעשתה בהסכמת כל בעלי הדירות בבית. בעדותה בעמ' 7 לפרוטוקול שורה 31, כבר טענה העדה כי ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות להם צמוד השטח "ג". בהמשך עדותה בעמ' 6 שורות 10-11, בעמ' 8 שורות 1-6 וכן בעמ' 8 שורות 10-15 עת נשאלה האם ניתנה הסכמתם של הבעלים שקדם לתובע השיבה כי אינה יודעת מי הם ועל כן אינה יודעת אם נתנו הסכמה.

39. נתבע מס' 2 העיד כי התובע הוא חליפו של מר מאיר, והלה נתן הסכמתו לבניית המחסנים, ראו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 36-38. בהמשך מעיד עד זה כי קיימים בעלי דירות נוספים להם צמוד שטח הקרקע "ג" אשר לא נתנו את הסכמתם. הנתבע אף מאשר כי כלל אינו מכיר אותם, ראו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 5-7.

40. נמצא אם כן כי לאור עדויותיהם אלו לא יכולה הייתה להינתן הסכמתם הפוזיטיבית של כל בעלי הדירות להם צמוד שטח "ג".

41. גם לא הוכחה הסכמה בע"פ של כל בעלי הדירות להם צמוד שטח "ג". הנתבעים לא טרחו להביא את הבעלים הקודמים של דירת התובע לעדות, לשם תמיכה בטענתם כי נתן הסכמתו לבניית המחסנים. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ראו ע"א 548/78 שרון נ. לוי פד ל"ה(1) 736 בעמ' 760, ע"א 2275/90 לימה נ. רוזנברג פ"ד מז (2) 606, ע"א 27/91 קבלו נ' שמעון פ"ד מט (1) 450, וכן ראו יעקב קדמי על הראיות-הדין בראי הפסיקה (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד), 1650.

42. לאור עדותם זו של הנתבעים, ממנה עלה כי כלל אינם מכירים את מקצת בעלי הדירות להם צמוד השטח "ג", ולאור אי הבאתו של הבעלים הקודם בדירת התובע לעדות נמצא כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח גם הסכמה בע"פ של כל בעלי דירות אלו.

43. אין גם כל הסבר מניח את הדעת מדוע לא דאגו הנתבעים להצמיד את המחסנים לדירותיהם או להסדיר את זכויותיהם בהם בין באמצעות הוראה תקנונית ובין באמצעות רישום בספר הפרוטוקולים של הבית.

44. יחד עם זאת, ועל כך אין חולק, המחסנים עומדים על תילם, משנת 1999 או בסמוך לכך, כ-14 שנים לפחות. מהראיות עלה כי לפחות עד שנת 2012 לא קמה התנגדות של מי מבעלי הדירות בבית לבניית או לשימוש אשר עושים בהם הנתבעים. הדבר עולה כדי רשות שימוש שבשתיקה. ואולם, בהתאם לפסיקה אשר פורטה לעיל, רשות זו הדירה עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון כאשר לא הוכחו הסמכות ושינוי מצב לרעה. הנתבעים לא העלו טענות בדבר השקעות שהשקיעו או הסתמכות ושינוי מצב לרעה, ורק טענו ל"צורך" במחסנים. לאור זאת מוצאת אני כי רשות זו ניתנת לביטול.

45. נשאלת השאלה האם מכוח דיני הקניין עומדת לתובע זכות לדרוש השבת המצב לקדמותו לגבי המחסנים, וזאת ללא כל מנגנון מאזן אשר יביא בחשבון גם את האינטרסים של הנתבעים ושיקולים של צדק והגינות. שאלה זו עמדה לדיון בע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה (ניתן ביום 19.2.12). באותו פסק דין עמדה לדיון השאלה האם יש להורות על הריסת חלק מדירת המשיבה אשר פלש אל תוך שטח שבבעלות המערער וקבע בית המשפט את הדברים הבאים:

"עקרון תום הלב מעוגן בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, ומכוח הוראת סעיף 61(ב) לחוק נפרש עקרון זה על פני החקיקה האזרחית כולה. על החובה לפעול בתום-לב ועל היקף פרישתה במשפט הישראלי, עמד בית המשפט לא אחת בציינו כי זוהי "אחת מאותן דוקטרינות כלליות החלות בכל תחומי המשפט ... על פיה, כל בעל זכות (במובנה הרחב) צריך להפעיל את זכותו בתום לב" (ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385, 400 (2003) (להלן: עניין גנז); כן ראו: ד"נ 7/81 פנידר, חברה להשקעות פתוח ובנין בע"מ נ' קסטרו, פ"ד לז(4) 673, 687 (1983); בג"ץ 1683/93 יבין פלסט בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, פ"ד מז(4) 708, 702 (1993); ע"א 700/81 פז נ' פז, פ"ד לח(2) 742, 736 (1984)).

אכן, ההגנה על הקניין מפני פגיעה יש לה מעמד חוקתי (סעיף 3 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו; ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221 (1995)). יחד עם זאת, בעלים של נכס ובכלל זה נכס מקרקעין, אינו נהנה מאוטונומיה מוחלטת בבואו להגן על החזקתו בנכס ואין לו זכות בלתי מסויגת ל"שרירות בעלים" (ראו למשל: יהושע ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף 26-27, 42-45 (1997) (להלן: ויסמן - בעלות ושיתוף); חנוך דגן קניין על פרשת דרכים 27-37 (2005)). יתכנו, אפוא, מקרים שבהם מכוח עקרון תום הלב יוגבלו הסעדים להם זכאי בעל זכות קניינית, הגם שזו נפגעה על-ידי הזולת (ראו: ע"א 782/70 רדומילסקי נ' פרידמן, פ"ד כה(2) 523, 530 (1971); עניין רוקר). מנגנון מאזן ברוח זו הנותן ביטוי לעקרון תום הלב אנו מוצאים בסעיף 14 לחוק המקרקעין, הקובע כי "בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" וכבר נפסק כי סעיף זה מבטא את עקרון "איסור השימוש לרעה בזכות", אשר ניתן לראותו "כבנה של דוקטרינת תום-הלב" (רע"א 1017/97 רידלביץ נ' מודעי, פ"ד נב(4) 625, 632 (1998)). ליחס שבין הוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין ובין עקרון תום הלב ראו עוד: ויסמן - בעלות ושיתוף, 69; עניין רוקר, 276-277, 287; עניין גנז, 401-402; מיגל דויטש, קניין - כרך א' 319-324 (1997) (להלן: דויטש); אורי ידן "העקרון של תום לב בחקיקה החדשה" ספר אורי ידן - האיש ופועלו כרך א' 281, 282-281 (א' ברק וט' שפניץ עורכים, 1990); אריאל רוזן-צבי "שימוש לרעה בזכות במקרקעין (לפרשנות סעיף 14 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969)" עיוני משפט ד 651, 669-670 (1975)). על כפיפותה של זכות הקניין

לעקרונות היסוד של שיטתנו ועל שיקול הדעת הנתון לבית המשפט בכל הנוגע להענקת סעדים שנועדו להגן על זכות הקניין, עמד פרופ' ויסמן באומרו:

"מכיוון שאין הבעלות מוחלטת עוד, ותוכנה נקבע בכל מקרה על-ידי שקילת האינטרס של הבעל לעומת האינטרס של שכניו ושל הציבור, מתחייבת מכך מעורבות רבה על-ידי בתי המשפט, המופקדים על מציאת האיזון הנאות שבין בעלי האינטרסים השונים" (ויסמן - בעלות ושיתוף, 45).

46. וראו גם את הדברים אשר נאמרו ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199 לגבי היקף שיקול הדעת המסור לבית המשפט בכל הנוגע להגנה על זכות הקניין, ואל השיקולים אשר יש בהם כדי להשפיע על אופן החלתו של עקרון תום הלב במקרה נתון.

47. מחומר הראיות שבא לפניי עלה כי הנתבעים ובעלי דירות נוספים בבית המשותף הגישו בשנת 2012 בבית משפט השלום בחדרה תביעה לסילוק ידו של התובע מחצר אשר לטענתם תפס בה התובע חזקה שלא כדין. לטענתם רק לאחר הגשת תביעה זו שלח התובע מכתבי התראה לנתבעים בהם דרש את הריסת המחסנים ולאחר שלא נענה הגיש תביעתו זו. הנתבעים טוענים כי כל מטרת הגשת תביעה זו הייתה להלך עליהם אימים ולגרום להם לוותר על תביעתם לפינוי ידו מהחצר.

48. לא מצאתי לקבל טענתם זו של הנתבעים ואפרט-

בדיון אשר התקיים לפניי ביום 26.12.13 העיד התובע (עמ' 4 שורות 6-7) כדלהלן:

"כשגילית שהמחסנים הם על השטח המשותף הוצאתי להם מכתבים לפיהם אני שותף במחסנים לפי הטאבו, ביקשתי גם זכות שימוש, אך הם לא חזרו אלי."

49. בדיונים אשר התקיימו לפניי הצעתי לצדדים הצעת פשרה ולפיה יבנה התובע אף הוא מחסן לעצמו בהמשך שורת המחסנים שבנו הנתבעים, ראו הצעתי בעמ' 9 לפרוטוקול הדיון שורות 16-34. שני הצדדים דחו הצעה זו (ראו הודעותיהם מיום 1.1.14 ו-5.1.14)

50. משום חובת תום הלב מצפה הייתי כי הנתבעים, אשר הקימו לעצמם מחסן על שטח הקרקע המשותף "ג", יאפשרו אף לתובע להקים מחסן דומה באותו השטח. אך לא היא, התובעים הודיעו, כאמור, כי אינם מוכנים לאפשר לתובע הקמת מחסן.

51. לאור זאת, לא מצאתי כי מכוח חובת תום הלב נכון להותיר את המצב על כנו באופן שרק הנתבעים יעשו שימוש ייחודי במחסנים נושא ההליך.

52. יחד עם זאת, גם לא מצאתי כי נכון להורות על סילוקם והריסתם של המחסנים, מקום בו מעיד התובע מפורשות (עדותו צוטטה בסעיף 49 לעיל) כי אף הוא מבקש לקבל זכות שימוש באותם מחסנים. יש לזכור כי בהקמתם של מחסנים אלו הושקעו כספים לא מבוטלים, ויכולה לצמוח הנאה מהם לכל הצדדים להליך. בנסיבות תיק זה, במקום בו יכולים התובע והנתבעים ליהנות מהמחסנים הקיימים ולעשות בהם שימוש נכון לדעתי להורות על מתן אפשרות שימוש בהם גם לתובע חלף מתן צו שיורה על הריסתם.

סוף דבר-

53. מוצאת אני לקבוע כי המחסנים נושא ההליך הם רכוש בבעלותם המשותפת של כל בעלי הדירות להם צמוד שטח "ג".

54. סעיף 30 לחוק המקרקעין קובע ביחס למקרקעין משותפים כדלהלן:

(א) "בעלי רוב החלקים במקרקעין המשותפים רשאים לקבוע כל דבר הנוגע לניהול הרגיל של המקרקעין ולשימוש בהם."

(ב) שותף הרואה עצמו מקופח מקביעה לפי סעיף קטן (א) רשאי לפנות לבית המשפט בבקשת הוראות, ובית המשפט יחליט כפי שנראה לו צודק ויעיל בנסיבות העניין."

55. לאור הוראת סעיף 30 לעיל, קובעת אני כי בעלי רוב החלקים בשטח "ג" יהיו רשאים לקבוע את אופן חלוקת השימוש בין התובע לנתבעים במחסנים אלו, ובלבד שתינתן אפשרות שימוש לתובע באחד המחסנים, בין ביחד עם בעלי דירה אחרים, בין באופן ייחודי, ובלבד שחלוקת השימוש לא תהא מקפחת.

56. זכות השימוש של התובע תחל בעוד 60 יום מהיום. פרק הזמן שניתן לקיומו של פסק הדין נועד לאפשר לבעלי הזכויות שהות על מנת להיפגש ולהסדיר את אופן השימוש במחסנים.

57. התובע גם עתר לצו ולפיו אורה לנתבעים לפרק שער אשר התקינו מדרום לבית באופן החוסם מעבר במקום. תביעה זו נזנחה ולא הוכחה. למעט תמונה המדגימה שער זה לא הוגשו כל ראיות בעניין והעדים לא נחקרו בנדון. מחומר הראיות לא עולה מי התקין שער זה והאם עודנו קיים. משכך מוצאת אני לדחות את העתירה לסעד זה.

58. לאור תוצאות ההליך ועל מנת ליתן סיכוי לשלום בית במקום לא מצאתי לחייב את הנתבעים בהוצאות.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ד' בסיון התשע"ד (2.6.14)

העתקים ישלחו לצדדים

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין